

1500473-14.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC - 687055624 - Rel. Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154)

PENA - Agravantes - Tráfico de entorpecentes - Associação - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500473-14.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500473-14.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085414/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 17028324 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI,

948/21/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2085414 - DEL.POL.BIRIGUI, 948/21/309 -

DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE SOUZA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1500473-14.2021.8.26.0603 (Controle nº 704/2021)

VISTOS.

RODRIGO DE SOUZA LIMA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06, porque, no dia 27 de março de 2021, por volta das 12h00min, na Rua Justino Fernando Calhiari, nº 1063, Portal da Pérola II, nesta cidade e comarca de Birigui, trazia consigo 02 (duas) porções de maconha, pesando um total de 191,87 gramas, e, 50 (cinquenta) porções de cocaína, pesando 41,10 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos periciais de fls. 22/23 e 166/174.

Ao acusado foi concedida a liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura (fls. 125/128).

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 219), cuja peça foi juntada às fls. 199/204, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 08 de junho de 2021 (fls. 220/221).

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 01 (uma) testemunha arrolada em comum, 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e 03 (três) testemunhas arroladas pela defesa, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 284/285).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu pela improcedência da ação, com a absolvição do acusado (fls. 305/309).

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, e a restituição do valor apreendido (fls. 311/319).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06).

De início, a alegação do réu quanto à busca domiciliar na casa sem mandado judicial, fica rejeitada.

Pelo que se relatou, os policiais militares foram designados para fazerem uma operação no município de Birigui, pelo Bairro Portal da Pérola II, quando adentraram na Rua Justino Fernando Calhiari, avistaram uma casa de esquina de nº 1063, com o portão aberto e um rapaz sentado em uma cadeira de área, manuseando o celular e com uma sacola plástica. Ao perceber a presença dos policiais, saiu correndo para o interior da residência, deste modo chamou a atenção dos policiais que foram ao seu encalço e conseguiram abordá-lo. Em seguida apuraram que no interior da sacola havia 50 (cinquenta) microtubos de cocaína e 02 (duas) porções de maconha, foi encontrada também a quantia de R\$ 1.239,60 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) em notas diversas.

Logo, evidente que houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial. Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam.

Assim, em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, no caso de flagrante delito, como foi o ora tratado.

Como se não bastasse, é cediço que, em se tratando de crime permanente, é dispensável qualquer exibição de mandado e também a presença de civis no local, até porque se sabe que, no mundo do tráfico, é comum as testemunhas não aparecerem para depor e são raras as pessoas que prestam depoimentos em juízo, tudo por receio de represálias e ameaças por parte dos traficantes. Desprezar, como regra, a ação dos policiais em caso como o dos autos, seria fechar os olhos para a nossa realidade, o que seria inadmissível.

Por fim, anoto que a matéria foi recentemente objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que cassou a decisão proferida anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas razões adoto, aqui, como razão de decidir, para afastamento dessa preliminar:

“De acordo com sólida orientação doutrinária e jurisprudencial há muito firmada, o tráfico de drogas é crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso no imóvel residencial ou congêneres, em qualquer dia e horário, independentemente de mandado judicial, na formodo disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A propósito: “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui delito permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente.” (Superior Tribunal de Justiça, HC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 11ª Câmara – Seção Criminal Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439 - Pereira Barreto 5 451502/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). Em função disso, sempre que houver fundada suspeita da ocorrência do referido ilícito penal, não será possível falar em ilegalidade na ação dos agentes públicos, nem em ilicitude da prova amealhada, por inexistência de mandado de busca prévio ou específico, ou por estar caracterizada a invasão domiciliar. Afirmar-se o contrário implicaria prestigiar a atividade criminosa, em detrimento do trabalho policial realizado por agentes

públicos regularmente investidos em suas funções, que ficariam inviabilizadas, com prejuízo irreparável para a sociedade. Imagine-se, por exemplo, que policiais estivessem realizando ronda rotineira, no exercício do policiamento preventivo e, ao passarem diante de uma residência qualquer, ouvissem gritos de socorro de uma mulher. A prevalecer o raciocínio segundo o qual o ingresso em residência só pode ocorrer quando houver segura conclusão acerca de crime em seu interior, mesmo diante da suspeitada ocorrência de violência doméstica, os agentes públicos estariam impossibilitados de intervir, e só poderiam ingressar na residência após a obtenção de ordem judicial, ou se a tanto autorizados pelo possível agressor, ou seja, quando o socorro à vítima já não seria mais útil. Tão absurda situação equivaleria à concessão de um passe livre para que residências servissem de palco para a prática dos mais diversos e graves delitos (homicídios, sequestros, lesões corporais, tráfico, estupro de vulneráveis, etc.), colocando a proteção às vítimas e da sociedade em patamar inferior aos direitos dos criminosos, e privilegiando a impunidade)... E nem se diga, por outro lado, que a diligência policial não foi devidamente documentada. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual se exigia documentação e registro audiovisual para o ingresso de policiais em residências (Habeas Corpus nº 598051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.342.077-SP, de que foi relator o Ministro Alexandre de Moraes, realizado no dia 02 de dezembro de 2021, ficando assentado que é “Incabível, portanto, na presente hipótese, em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias, para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE”. Enfim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, nem é o caso de se determinar o desentranhamento de qualquer elemento probatório dos autos, já que todas as provas produzidas se afiguram válidas. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439, Comarca de Pereira Barreto, 11ª Câmara de Direito Criminal, V.U., j. 03/02/22, rel. Des. XAVIER DE SOUZA).

No mérito, a ação penal é procedente, respeitando o entendimento exposto pela acusação e defesa em suas alegações finais.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/03); o boletim de

ocorrência (fls. 04/07); a nota de culpa (fl. 24); o auto de exibição e apreensão (fls. 16/17); o relatório final (fls. 182/185); os laudos de constatação prévia (fls. 21/23); os laudos periciais (fls. 166/174); o depósito judicial (fl. 180); os depoimentos das testemunhas; e as indigestas negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Tanto na delegacia, quanto em juízo, o réu disse que a droga encontrada não lhe pertencia e que o policial buscou uma sacola dentro da viatura com as drogas. Sobre o dinheiro apreendido, afirmou ser de sua esposa, proveniente da venda de roupas femininas. Disse que estava dentro da residência com sua esposa e os dois filhos, quando os policiais militares invadiram sua casa. Afirmou que foi agredido pelos policiais militares. Disse que foi o policial Alberto quem buscou uma sacola contendo drogas na viatura para prejudicá-lo, e que conhece o policial Doná, o qual o agrediu na presença de vários vizinhos. Relatou que foi ameaçado de morte pelos dois policiais (fls. 14/15 e 284/285).

Contudo, a negativa apresentada pelo réu não merece credibilidade, pois está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal pela conduta efetivamente praticada.

Com efeito, as testemunhas Marcelo Alberto dos Santos e Wellington Rodrigo Doná, Policiais Militares, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, disseram que realizavam patrulhamento, quando avistaram um rapaz sentado em uma cadeira de área manuseando um telefone celular e com uma sacola plástica e, ao perceber a aproximação da viatura, o rapaz correu para o interior da residência. Diante da atitude suspeita, abordaram o acusado Rodrigo. Na garagem da casa localizaram uma sacola, contendo 50 (cinquenta) microtubos de cocaína, porções de maconha e a quantia de aproximadamente R\$1200,00, em notas diversas. O acusado ofereceu resistência, sendo necessário o uso de força moderada, começou a gritar para que os vizinhos o ajudassem. Indagado, negou que a propriedade das drogas, afirmando que havia um “menino” com ele e que a droga poderia ser dele, mas não informou quem seria essa pessoa. Quanto ao dinheiro, o acusado disse que seria de sua esposa, referente à venda de lingerie. Disseram que não conheciam o acusado. Em juízo, Marcelo acrescentou que o acusado acompanhou a busca domiciliar, por sua vez Wellington disse que o réu não acompanhou as buscas na residência, e que o dinheiro foi localizado no quarto (fls. 08/09, 10/11 e 284/285).

Como se vê, os policiais foram categóricos em afirmar que encontraram, dentro do imóvel, os entorpecentes que foram dispensados pelo acusado. Ademais, o réu teria dito aos policiais que a droga poderia ser de uma terceira pessoa que estava com ele no local e fugiu, mas em momento algum o réu quis dizer o nome do indivíduo, lembrando que os policiais afirmaram que não viram ninguém com o réu antes da abordagem.

Ainda quanto aos policiais, anoto que pequenas divergências entre seus depoimentos que não afetam, no substancial, a apuração da verdade, devem ser consideradas como fruto da capacidade de observação de cada um, tratando-se de lapso corriqueiro na evocação da memória descritiva, não maculando o fato principal. Aliás, como tem reconhecido a jurisprudência, pequenas contradições demonstram que elas disseram a verdade e não montaram seus depoimentos. Logo, como essas pequenas contradições não maculam o fato principal narrado na denúncia.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terá valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

Descabida, portanto, a alegação do réu de que os policiais teriam forjado um flagrante, porque, em nenhum momento, restou comprovado nos autos que os policiais conheciam ou tinham algum interesse na prisão do acusado.

No caso em tela, isto não ocorreu. Após abordagem ao réu, que teria tentado se evadir ao avistar a viatura policial, dispensando uma sacola, os policiais constataram que havia porções de cocaína e maconha dentro da sacola plástica, sem ter existido qualquer tipo de preparação por parte da polícia.

Logo, não se pode aceitar a tese de flagrante preparado (forjado). Para que exista este tipo de flagrante, necessário é que a polícia se arme de meios para efetuar a prisão, mas com induzimento à prática da infração penal.

Esta, aliás, é uma das Teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça sobre prisão em flagrante: "O tipo penal descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo", antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva de flagrante preparado". De outra parte, não prospera também a alegação do acusado de que foi agredido pelos policiais, já que tal alegação não foi amparada por qualquer prova produzida pelo réu. Ademais, neste ponto, importante ressaltar que os policiais informaram que o réu tentou resistir à abordagem e foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo.

No mais, já houve análise na audiência de custódia, sendo que, naquela ocasião, determinou-se a expedição de ofício para Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos.

A testemunha Jéssica Priscila de Jesus Souza, esposa do acusado, ouvida em ambas as fases da persecução penal, disse que estavam na residência, quando policiais militares ingressaram no imóvel perguntando sobre a existência de drogas. Relatou que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de lingerie. Não viu nenhuma sacola com drogas. O acusado conhecia o policial Doná, mas ele nunca teve nenhum problema com a Polícia Militar (fls. 12/13 e 284/285).

A testemunha Aparecido Lima, genitor de Rodrigo, ouvido na delegacia, relatou que viu os policiais agredindo o acusado, bem como afirmou que um deles havia se apossado de uma sacola azul, dentro da viatura, e retornado ao imóvel, "forjando" aquelas drogas como se fossem de seu filho. Em juízo, alterou totalmente sua versão dos fatos, disse que chegou ao local e seu filho já estava algemado dentro viatura policial e não presenciou os fatos (fls. 163 e 284/285).

Os depoimentos das testemunhas Jéssica e Aparecido, no entanto, não podem prevalecer sobre os demais elementos de prova colhidos na instrução. Primeiro, porque são parentes do réu e depuseram sem o compromisso de dizer a verdade sobre os fatos. Segundo, porque a testemunha Aparecido, pai do acusado, afirmou que sequer presenciou os fatos, alterando totalmente, em juízo, seu depoimento prestado na delegacia, logo, seus depoimentos contraditórios não são suficientes para afastar os depoimentos dos policiais. Terceiro, porque não se pode dar a mesma credibilidade dado aos testemunhos dos policiais, porque se trata da esposa e do pai do réu, e, suas narrativas tiveram por fim tentar afastar a responsabilidade penal do acusado. Por prestarem depoimento sem compromisso, entretanto, estas testemunhas não respondem por crime de falso testemunho.

A testemunha Lourdes de Carlos Chagas, ouvida em juízo, não presenciou os fatos, apenas relatou que fornecia roupas íntimas femininas à esposa do acusado para revender (fls. 284/285).

Tal depoimento, no entanto, não é suficiente para comprovar a origem do dinheiro, como pretendido pelo acusado e sua defesa.

A testemunha Augusto de Oliveira Rodrigues, na fase judicial, relatou que viu os policiais militares ingressando ao imóvel de seu vizinho, ouviu o réu gritando e foi verificar o que estava ocorrendo. Disse que viu os policiais militares agredindo o acusado, o qual negou a propriedade dos entorpecentes que havia sido "plantado" pelos policiais. Por fim, afirmou que foi ameaçado pelos policiais militares para não filmar a ocorrência (fls. 284/285).

Esse depoimento, se cotejado com os demais elementos de prova, não pode merecer a

mesma credibilidade, uma vez que ficou demonstrado que a testemunha agiu com a intenção de afastar a responsabilidade do acusado.

Aliás, a alegação dessa testemunha de que foi ameaçado pelos policiais não prospera, já que tal alegação não foi amparada por qualquer prova produzida nos autos.

Sabe-se que os cidadãos bem-intencionados não admitem mais conviver com repressões passadas que foram sepultadas pelo Estado Democrático de Direito instalado em nosso País na atualidade.

As afirmações da testemunha acerca das ameaças feitas pelos policiais são inconsistentes, porquanto, se efetivamente pressionado ou agredido, insurgir-se-ia de pronto e tomaria, logo em seguida, as medidas necessárias para que o policial fosse punido, mas nada disso se vê nos autos, motivo pelo qual não se pode dar credibilidade a sua versão.

Diferentemente dos parentes do réu, esta testemunha responderá pelo crime de falso testemunho.

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consiste realmente em "maconha" e "cocaína" (exames químicos-toxicológicos de fls. 166/174).

De outra parte, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, ou seja, 02 (duas) porções de maconha, totalizando 191,87 gramas e 50 (cinquenta) porções de cocaína, totalizando 41,10 gramas; as circunstâncias da abordagem do réu (ao notar a presença dos policiais, correu para o interior da residência); a forma de acondicionamento das drogas (distribuídas em pequenas porções, prontas para o comércio), e a apreensão de dinheiro (R\$ 1.239,60) em notas diversas, evidenciam a traficância.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Lembre-se que o réu foi denunciado por trazer consigo a droga.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado não conseguiu provar pertencer a sua esposa, proveniente de vendas de roupas, não sendo suficiente o depoimento da testemunha Lourdes, já que ela tão-somente afirmou que fornecia roupas íntimas femininas à esposa do acusado para revender. Assim, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente ali praticado.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado trazia consigo 191,87 gramas de maconha e 41,10 gramas de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado ostenta Maus antecedentes (fls. 322/323 - Proc. nº 0001284-

05.2007.8.26.0097 e fls. 323/324, Proc. nº 0003132-90.2008.8.26.0097), razão pela qual as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhe são favoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Afora isso, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado (nada menos do que 191,87 gramas de maconha e 41,10 gramas de cocaína), se fosse

alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes. Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e consequências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repreensão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154)

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, nos aspectos acima relatados (quantidade da droga e maus antecedentes), elevo a pena-base acima do mínimo legal em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 324/325 - Proc. nº 0051581-97.2008.26.0576) e aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Neste ponto, não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque, entre os requisitos legais para tal benefício, o acusado deve ser primário e possuir bons antecedentes, condições estas que o réu não ostenta.

Ademais, ainda que o réu fosse primário e não ostentasse maus antecedentes, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de

peessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, o que só vem confirmar a não incidência da causa de diminuição supracitada. Torno definitiva a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RODRIGO DE SOUZA LIMA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênica, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (deseestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem esses argumentos, anoto ainda que o acusado é reincidente, ostenta maus antecedentes e a pena fixada ultrapassa quatro anos, o que afasta também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O acusado foi solto mediante liberdade provisória concedida na audiência de custódia e assim permaneceu durante a instrução, razão pela qual poderá continuar a responder ao processo em liberdade.

A incineração da droga já foi determinada e realizada (fls. 229/230), nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Demonstrada a procedência ilícita do dinheiro apreendido às fls. 16/17 (R\$ 1.239,60), não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente, razão pela qual, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro depositado à fl. 180.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado (dinheiro), instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto ao rolo de papel filme, apesar de serem instrumentos do tráfico de drogas praticado pelo acusado, diante da sua natureza, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos. Após o trânsito em julgado, oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro e destruição do objeto, instruindo-se o ofício com as cópias mencionadas no parágrafo anterior.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com fundamento nos artigos 40 e 211, caput, do Código de Processo Penal, determino que se extraiam cópias das fls. 08/09; 10/11, 12/13, 14/15, 80/82, 163 e da presente sentença, encaminhando-se à Promotoria de Justiça Criminal local, para, se for o caso, apurar a prática de crime de falso testemunho cometido, em tese, por Augusto de Oliveira Rodrigues.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA